

0001511-50.2017.8.26.0515

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Comarca: Rosana

Foro: Foro de Rosana

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... apenas a condenação de Anderson pelo crime de tráfico de drogas, pois evidenciado que mantinha e guardava drogas para o tráfico.

Outrossim, quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, o caso é de absolvição de Anderson e Marcelo.

Realmente, o conjunto probatório não é suficiente para revelar a existência de associação permanente e estável entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rosana

Foro de Rosana

Vara Única

Rua Curimbatá, 788/802 QD 12 - D. Primavera, Primavera-SP - cep 19274-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001511-50.2017.8.26.0515 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001511-50.2017.8.26.0515

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 92/2017 - 1º Distrito Policial de Rosana

Autor:

Justiça Pública e outros

Indiciado:

NORIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DA SILVA, JOSÉ PIRES, NORIVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA, WESLEI AMARAL JACUBOVSKI, JOÃO DE DEUS, YAGO DIAS DE OLIVEIRA, MATEUS ARAÚJO DOS SANTOS, LEONARDO DE SOUZA AZOLINI, CÍCERA GERALDA DOS SANTOS e LEANDRO BATISTA SIQUEIRA foram denunciados como incurso no artigo 33, com as causas de aumento de pena do artigo 40, incisos IV, V e VI e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque "em diversas datas, horários e locais, todos situados nesta cidade e comarca de Rosana, durante os anos de 2016 e 2017, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, ainda que gratuitamente, drogas, para fins de consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo certo que tais entorpecentes eram trazidos para esta cidade de Rosana pelos acusados, e por outras pessoas ainda não identificadas, de outros estados da Federação (Paraná e Mato Grosso do Sul), bem como que a prática dos delitos envolvia adolescentes e que os crimes eram praticados com emprego de arma de fogo". Consta ainda que "em data, local, e horários incertos, porém durante os

anos de 2016 e 2017, nesta cidade e comarca de Rosana, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006" (fls. 01/02).

A fls. 996/1007, foi determinada a notificação dos acusados.

Os acusados foram notificados e ofereceram defesa prévia (José Pires - fls. 1061/1069, Cícera - fls. 1114/1118, Leonardo - fls. 1124/1125, Mateus - fls. 1162/1170, João de Deus - fls. 1178/1183, Norivaldo - fls. 1189/1190, Anderson - fls. 1191/1193, Yago - fls. 1223/1225, Marcelo - fls. 1324/1348, Wesley - fls. 1393/1399, Leandro - fls. 1693/1695).

A denúncia foi recebida em 31 de setembro de 2018 (fls. 1817/1818).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados.

A fls. 3379, foi extinta a punibilidade do acusado JOSÉ PIRES, em razão da notícia de seu falecimento, com fundamento no artigo 107, I, do Código Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação pena para: a) condenar os réus ANDERSON APARECIDO DA SILVA, vulgo "Nenê" ou "Olhos Verdes"; NORIVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, vulgo "Cabeça ou Cabeção"; WESLEY AMARAL JACUBOVSKI, vulgo "Magrinho ou Magrelo"; JOÃO DE DEUS FILHO; YAGO DIAS DE OLIVEIRA; LEONARDO DE SOUZA AZOLINI, vulgo "Leozinho"; e CÍCERA GERALDA DOS SANTOS, vulgo "Cissa", pelos crimes: (1) artigos 33 c.c. 40, inciso V (tráfico de drogas majorado); e (2) artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; b) CONDENAR o réu MARCELO DOS SANTOS FERREIRA pelo crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06; c) ABSOLVER os MATEUS ARAÚJO DOS SANTOS e LEANDRO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (fls. 3474/3535).

A Defesa da ré Cícera apresentou alegações finais a fls. 3543/3612, pugnando, em suma, por sua absolvição pela ausência de provas ou insuficiência de provas; subsidiariamente, fez pedidos quanto à dosimetria da pena.

A Defesa do réu Norivaldo apresentou alegações finais a fls. 3617/3626, pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas.

A Defesa do réu Anderson apresentou alegações finais a fls. 3627/3634, pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pelo direito de recorrer em liberdade e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa do réu Marcelo apresentou alegações finais a fls. 3635/3645, alegando que o acusado já foi denunciado e condenado pelos mesmos fatos narrados na presente denúncia. Afirmou que não há prova da materialidade delitativa, de modo que deve ser absolvido pela ausência de provas.

A Defesa do réu Wesley apresentou alegações finais a fls. 3646/3654, pugnando pela absolvição pela ausência de provas.

A Defesa do réu Yago ofereceu alegações finais a fls. 3655/3663, pugnando pela absolvição pela ausência de provas.

A Defesa do réu Leandro ofereceu alegações finais a fls. 3670/3672, requerendo sua absolvição pela falta de provas.

A Defesa do réu Mateus ofereceu alegações finais a fls. 3676/3682, requerendo sua absolvição pela insuficiência das provas.

A Defesa do réu João de Deus ofereceu alegações finais a fls. 3685/3693, requerendo sua absolvição por falta, ou, ainda, por insuficiência da prova. Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do réu Leonardo, por fim, ofereceu alegações finais a fls. 3700/3703, pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pelo direito de recorrer em liberdade e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, o caso é de reconhecimento de nulidade da ação penal desde seu início em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 imputado ao acusado Marcelo. Isto porque o réu já foi processado e condenado nos autos nº

0000213-07.2017.8.26.0585 pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de entorpecentes em sua residência por ocasião da deflagração da operação policial que deu origem à presente ação penal (operação "Judas Iscariotes"), tanto assim que o próprio Parquet requereu, nestes autos, sua condenação apenas pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas (fls. 3529). Como é cediço, um dos princípios basilares do direito penal é o princípio da vedação à dupla incriminação (princípio ne bis in idem), é dizer, a vedação de que uma pessoa seja processada, julgada ou condenada mais de uma vez pela mesma conduta. A despeito de não se tratar de princípio expressamente previsto na Constituição Federal, é inegável sua aplicação no ordenamento jurídico pátrio, como já ressaltou, em diversas ocasiões, o E. Supremo Tribunal Federal: "a lei brasileira não admite seja o indivíduo processado criminalmente por delito pelo qual foi condenado, consagrando a regra, que vem do direito romano, do non bis in idem: não se pune duas vezes a um acusado pelo mesmo crime" (STF, Ext. 871-4/República da Grécia, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12.03.2004). No mesmo sentido: "A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já previsto pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de acusar" (STF, HC 80.263/SP, Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 27.06.2003) Anote-se que tal princípio incide tanto no âmbito processual quanto material, consoante didática exposição do e. Ministro Rogério Schietti Cruz: "Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impossibilita tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade, ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para se definir a sanção criminal". (RHC 132.655/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Nesse cenário, considerando que o acusado Marcelo já foi anteriormente processado em razão dos mesmos fatos a ele imputados nestes autos quanto ao delito de tráfico de drogas, forçoso reconhecer que a presente ação penal, neste ponto, padece de nulidade insanável desde seu início.

No mais, o feito se encontra formalmente em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, inexistindo outros vícios ou nulidades a serem sanadas.

A denúncia é parcialmente procedente.

Com efeito, ao cabo da instrução processual, ficaram comprovadas apenas a materialidade delitiva e a autoria imputadas ao acusado Anderson.

Se não, vejamos.

De início, anote-se que é admitida a comprovação da materialidade de modo indireto, ainda que não apreendidos entorpecentes. A respeito: "É possível a deflagração da ação penal e eventual condenação por crime de tráfico de drogas quando não há apreensão da droga nem a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito com base em outras provas, tais como a testemunhal ou a interceptação telefônica. Isso porque, nessa situação, há lastro mínimo de elementos informativos suficientes a evidenciar a tipicidade da conduta" (REsp n. 1.800.660/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 25/5/2020.)

No caso dos autos, apenas foram apreendidos 0,7g de "maconha" na posse do acusado Marcelo, ensejando a denúncia pela prática de tráfico de drogas objeto dos autos nº 0000213-07.2017.8.26.0585. Quanto aos demais acusados, nada de ilícito foi encontrado durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Juízo (fls. 521/579).

Nada obstante, as conversas telefônicas interceptadas, em especial aquelas entre Marcelo e Anderson (fls. 748/752, 755), revelam o comércio de entorpecentes, havendo diversas menções a vendas e transações em dinheiro entre eles. A título de exemplo:

Fls. 750:

Fls. 755:

De seu turno, apenas ficou comprovada nos autos a autoria atribuída ao acusado Anderson, não havendo elementos probatórios suficientes quanto aos demais acusados. O acusado Weslei, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que é usuário de drogas, já foi internado duas vezes, mas não vende. É servente de pedreiro. Estava trabalhando como gerente do hotel que pertence a seu sogro. Sobre a ligação que refere a “dez caixas de carne”, diz que apenas estava pedindo dez reais de droga para fumar. Não nega o conteúdo das conversas, mas reitera que apenas estava comprando. Não sabe dizer se os outros acusados são traficantes. Usava drogas junto com o Marcelo. Na primeira fase da operação, a polícia fez busca em sua casa e não encontraram nada. O acusado Anderson negou os fatos. Não sabe porque está sendo acusado. Não é usuário de drogas. Nunca usou o telefone de Marcelo ou de José Pires. Não conhece “Lobó”. Não apresentou explicações para as mensagens e ligações interceptadas. O acusado João negou as acusações e disse que foi acusado porque estaria sendo “perseguido” pelo delegado da cidade. É taxista. Disse que prestava serviços para uma financeira e que esta lhe pediu que tirasse fotografia de um carro financiado que estava com prestações atrasadas. Depois ficou sabendo que era o carro do delegado. Conhece José Pires, levou ele em algumas corridas. Não conhece os outros acusados.

O acusado Mateus negou os fatos. Conhece os outros acusados de vista, porque a cidade é pequena. É usuário de droga. Não conhece Cícera nem Vitor Oliveira. O acusado Leonardo negou a acusação. Negou que seu apelido seja Leozinho. Na época dos fatos não estava morando em Rosana. Morava em Santo Anastácio com seu pai, em um sítio. Morou em Rosana quando era adolescente, antes de ir para a Fundação Casa. Era usuário de drogas, comprava em Anastácio, na linha do trem. Não tem nenhuma relação com Marcelo, apenas conhece de vista. Nega ter falado ao telefone com Marcelo. Não conhece Cícera, José Pires, João de Deus. Conhece Norivaldo. Conhece Yago de vista, já falou com ele em festa. Não conhece Mateus. Conhece Pedro Henrique. Não sabe quem é Italiano. Sua mãe é chamada Daniele, não sabe se ela namora com a pessoa de Tiago. Acha que foi envolvido nas investigações porque deu muito trabalho na cidade quando era adolescente.

O acusado Marcelo negou os fatos. Disse que é dependente químico, já usou maconha, cocaína e crack, já foi até internado. As ligações interceptadas diziam respeito a tentativas de localizar drogas. Conhecia Anderson, Mateus, Norivaldo, porque eles também usavam drogas. Diz que sempre trabalhou, desde os 18 anos. Houve busca na sua casa, quando encontraram 1g de maconha, que era um “baseado” para o próprio uso, mas foi condenado pelo tráfico. Nunca vendeu drogas. A casa de José Pires era um local para consumo de drogas (“fumódromo”). Pelo que lembra, a ligação sobre uma quantia de José Pires dizia respeito a um empréstimo que ele fez. Buscava o dinheiro porque achava que iria conseguir droga para usar. Nunca teve negócio com Cícera. Norivaldo é usuário também. João de Deus é taxista, é tudo que sabe sobre ele. Já fumou maconha com Weslei. Conhece pouco Yago. Sobre a conversa que menciona câmeras, disse que estavam preocupados em ser flagrados usando drogas, e não que fosse implantar câmeras. Não conhece Gabriel, sempre recebia ligações porque as pessoas o consideravam um “noia” e o procuravam para usar junto. Weslei tinha um bebê pequeno na época e estava encostado por causa de um acidente de moto, então às vezes fazia favores para ele, pagava a conta de água dele na lotérica, ia no mercado. Fazia isso por camaradagem pois os dois eram usuários, sempre pensando que depois poderiam usar drogas juntos. Conhece Bebezão de nome, mas não era do seu círculo.

O acusado Yago negou os fatos. Disse que tinha saído recentemente da Fundação Casa e que logo depois foi deflagrada a operação Judas Iscariotes. Cometeu ato infracional equiparado a tráfico de drogas, roubo tentado e furto tentado. Foi intimado pelo Delegado para comparecer à delegacia e assim o fez, mas ao ali chegar recebeu voz de prisão. Não trocou mensagens com os outros acusados. Conhece Leonardo, desde pequeno, assim como Mateus e Anderson. Negou ter ido buscar drogas

em Nova Londrina. Conhece Weslei, não sabe se ele tem apelido. Já jogou bola com Janilson, não trocou mensagens com ele. Nunca ameaçou autoridades da cidade. Já viu José Pires no bar de seu tio. Não sabe se Anderson tem apelido, só tem uma amizade de vista.

O acusado Norivaldo negou a acusação. Disse que seu sobrinho Vitor foi preso na primeira fase da operação. Na época estava trabalhando em Penápolis, não estava nem na cidade. Tinha voltado para passar férias quando foi preso. É usuário de drogas. Já usou drogas com outros acusados, menciona Marcelo, Renato, Anderson, bastante gente. Comprava drogas por intermédio de outras pessoas. Não conhece Cícera. Já teve uma namorada Caroline. Saiu da cidade para trabalhar, não estava fugindo. Não ficou sabendo que estava sendo investigado na operação Judas Iscariotes. Nenezão é Rogério. Não sabe quem é Jeferson.

A acusada Cícera não foi ouvida em Juízo, tendo sido declarada revel (fls. 3331). A testemunha Ramon Euclides, delegado de polícia, descreveu as investigações. Relatou que, ao término da primeira fase da operação, verificaram que havia muitos indivíduos relacionados com os que foram presos na primeira fase. Instaurado novo inquérito policial, as interceptações continuaram inicialmente com um número que mantinha contato com Janilson, preso na primeira fase. Foram feitas mais de quatro mil horas de interceptação telefônica. Foi identificado novo núcleo que atuava em Primavera, de forma estável e associada entre eles na venda de drogas. Foi identificada uma fornecedora de drogas para esses indivíduos, Cícera, moradora de Nova Londrina/PR. Esclareceu a dinâmica do grupo: Anderson coordenava os demais indivíduos, tinha uma íntima a relação com Marcelo e José Pires; ele tinha contato também com Norivaldo com quem combinou de completar drogas para terem uma quantidade maior. Contou que uma testemunha ouvida nos termos do provimento 32, por ser próxima ao núcleo, conseguiu especificar o que cada um fazia: Anderson era responsável por receber a droga e repassar, em especial para Mateus e Yago, para revenda. Marcelo seria usuário, mas também intermediava a venda para outros traficantes da cidade. Marcelo, Mateus e Yago eram os principais responsáveis pela venda ao usuário final. Weslei é traficante; João de Deus é taxista, mas prestaria serviços auxiliando o tráfico. Yago e Mateus mantinham drogas. Norivaldo trazia droga para ser revendida. Leozinho é sempre mencionado nas conversas de diversos traficantes. Leandro foi indiciado pois tentava trocar um Cadete por maconha, mas a venda não deu certo. Cícera foi identificada como sendo vendedora de drogas em Nova Londrina. Na casa de Cícera e na propriedade rural não foi encontrada droga. Não se recorda da participação de menores neste núcleo, mas há indícios de tráfico interestadual.

A testemunha sigilosa 1 não recordou nenhum fato específico quanto aos acusados. Afirmou apenas que sabe que Weslei sempre teve envolvimento com o pessoal do tráfico.

A testemunha sigilosa 2 contou que houve uma grande operação em Rosana, chamada "Judas Iscariotes". Disse que João de Deus é taxista e que era suspeito de transportar a droga. José Pires tinha envolvimento com alguns dos outros indivíduos, não sabe se já faleceu. Além de ser usuário, havia suspeita de que ele trazia droga do Paraná ou do Mato Grosso do Sul. Não se recorda como seria feito o transporte. Não se recorda de quem era Norivaldo. Não recorda quem era Marcelo nem Weslei. Não participou muito nesta fase da operação, participou mais da primeira. Yago era suspeito de traficar na escola. Mateus, se for a pessoa que está pensando, usava a venda de lanches da tia para vender drogas. Ele foi apreendido com pouca quantidade de maconha, algumas vezes. Leozinho é traficante, já foram feitas várias buscas domiciliares, mas foram achadas poucas porções. A suspeita era que ele enterrava no quintal ou no Cinturão Verde, foi usado até o canil mas não localizaram maiores quantidades. Ele postava fotos armado nas redes sociais. A mãe dele, vulgo "Loira", foi presa por roubo. Não se recorda de Cícera nem de Leandro. Não participou de diligências na segunda fase, não foi convocada. Na primeira fase foram apreendidos entorpecentes e celulares.

A testemunha sigilosa 3 que foram chamados para fazer um levantamento de pessoas com envolvimento no tráfico e que apresentaram para o Ministério Público. Afirmaram que Leozinho já foi pego várias vezes com droga e que foi autuado.

A testemunha sigilosa 4 contou que na primeira fase, passou algumas informações para o Ministério Público e que depois não teve mais contato com a operação. Ratifica a declaração prestada quanto a Leozinho. Não sabe nada sobre os demais acusados.

A testemunha sigilosa 7 contou que não participou da segunda fase da operação. Prestou informações para o Ministério Público, que repassou para o Delegado, desencadeando a primeira fase da operação. Ratifica todas as informações passadas quanto a Norivaldo, Leozinho e ao Weslei. Não participou das investigações, elas competem à Polícia Civil.

A testemunha Alexandre Alberto, policial militar, contou que, no mês de dezembro, foi acionado pelo COPOM porque haveria um indivíduo no Hotel Felina fazendo uso e, possivelmente, embalando drogas. Chegando lá, realmente havia uma pessoa que dizia ter feito uso de crack. Havia cheiro de crack, mas não foi apreendido nada. Ele disse que João de Deus que iria trazer mais droga para ele e que a aquisição era realizada de uma pessoa chamada Pires. Lembrou que, anteriormente, já havia sido chamado para fazer uma busca no carro desse mesmo taxista chamado João de Deus. Nessa abordagem, nada havia sido encontrado com João de Deus. Relatou os fatos ocorridos no hotel ao delegado.

As testemunhas de Defesa, de seu turno, nada disseram que pudesse esclarecer os fatos.

Pois bem.

Ainda que existam indícios de que a maioria dos acusados esteja envolvida com negócios ilícitos, certo é que, ao cabo da instrução processual, não é possível concluir, com a certeza que se exige, de que praticavam os delitos descritos na denúncia.

De fato, há de se ressaltar que, a despeito do cumprimento de inúmeros mandados de busca e apreensão domiciliar, não foram apreendidos entorpecentes em posse dos acusados, com a exceção de 0,7g de "maconha" na posse do acusado Marcelo (processo nº 0000213-07.2017.8.26.0585).

Ademais, considerando que diversos acusados afirmam ser usuários de drogas, tampouco é possível se extrair, das conversas e mensagens interceptadas, que estivessem necessariamente comercializando drogas e não apenas as adquirindo para consumo próprio. Do mesmo modo, os diálogos mencionando a presença policial em determinados locais ou o avanço das investigações da operação "Judas Iscariotes" tampouco se prestam, por si só, a confirmar os fatos da denúncia, mesmo porque os acusados não negam seu envolvimento com o uso de drogas, o que já bastaria para explicar tais mensagens. Vale ressaltar, ainda, que em diversos diálogos, são utilizadas expressões genéricas que são interpretadas pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público como se referindo a drogas (negócio, pão, coisas, moeda, paradinhas, dentre outros), o que, embora comum na prática delitiva, não permite a certeza necessária para condenação, à míngua de elementos mais concretos que demonstrem que efetivamente se tratava de drogas.

Apenas os diálogos envolvendo Anderson, Marcelo e José Pires revelam a efetiva traficância, podendo se verificar, pelos diálogos, ocasião em que Marcelo foi buscar drogas com Anderson para revenda a terceiros. A exemplo:

Fls. 748/751:

Ocorre que, como já ressaltado anteriormente, Marcelo já foi processado e julgado pelos fatos descritos na denúncia no que toca à imputação do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, de modo que não é cabível sua nova condenação, sob pena de bis in idem. De seu turno, José Pires faleceu e teve sua punibilidade extinta nestes autos, remanescendo, portanto, apenas a condenação de Anderson pelo crime de tráfico de drogas, pois evidenciado que mantinha e guardava drogas para o tráfico.

Outrossim, quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, o caso é de absolvição de Anderson e Marcelo.

Realmente, o conjunto probatório não é suficiente para revelar a existência de

associação permanente e estável entre Anderson e Marcelo ou com terceiros. As conversas e provas produzidas nos autos não indicam a existência de um esquema permanente e organizado entre eles, tudo indicando que, por ocasiões, um ajudaria o outro fornecendo entorpecentes para revenda, porém cada um deles mantendo suas próprias atividades. Veja-se, nesse sentido, o diálogo de fls. 755, que evidencia que Anderson e Marcelo realizam seus próprios negócios de forma independente, tanto que Anderson informa que parou com a venda e que uma de suas operações não deu certo:

E, como é cediço, com relação à associação para o tráfico, é essencial a prova da estabilidade e permanência da aliança, não bastando uma associação eventual ou accidental entre duas pessoas, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial: "Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. (...) Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa." (NUCCI, Guilherme de Souza; Leis Penais e Processuais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). No caso, porém, como visto, não ficou evidenciada tal ligação perene e estruturada, havendo notícia apenas da eventual concurso de agentes para o tráfico de entorpecentes. Assim, inexistindo provas seguras e concretas a demonstrar a prática do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, em todos os seus elementos típicos, de rigor a solução absolutória quanto a esse crime no que toca aos acusados Anderson e Marcelo.

No mais, não é possível a condenação dos demais acusados com base na prova testemunhal, seja pelo crime do artigo 33, seja pelo crime do artigo 35, ambos da Lei de Drogas, uma vez que as testemunhas arroladas pela acusação que se limitaram a apontar que os acusados seriam conhecidos na cidade como traficantes ou por ter envolvimento com o meio do tráfico de drogas, sem descrever fatos específicos imputados a eles. Ora, como se sabe, o Direito Penal se dedica aos fatos, que devem ser especificados em suas circunstâncias de tempo e local, não bastando assim acusações genéricas, que até mesmo inviabilizam a adequada defesa.

No mais, as conversas interceptadas envolvendo os demais acusados não permitem concluir se apenas estariam adquirindo drogas para uso próprio ou para a traficância. Vale ressaltar que "no processo penal, prova positiva é ônus do Ministério Público, não cabendo aos réus comprovarem fato negativo indeterminado" (AgRg na APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 22/9/2020), é dizer, o ônus probatório compete à acusação, que deveria demonstrar nos autos os fatos alegados em sua denúncia.

Nesse cenário, quanto aos acusados NORIVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, WESLEI AMARAL JACUBOVSKI, JOÃO DE DEUS, YAGO DIAS DE OLIVEIRA, MATEUS ARAÚJO DOS SANTOS, LEONARDO DE SOUZA AZOLINI, CÍCERA GERALDA DOS SANTOS e LEANDRO BATISTA SIQUEIRA, o caso é de absolvição por insuficiência de provas. Do mesmo modo, tal é a solução quanto ao delito de associação para o tráfico imputado aos acusados ANDERSON APARECIDO DA SILVA e MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA.

Em suma, apenas em relação ao delito de tráfico de drogas imputado ao acusado ANDERSON APARECIDO DA SILVA é que há se falar em condenação, pois demonstrado que guardava e tinha em depósito entorpecentes, para fins de venda a terceiros. Devem ser rechaçadas, porém, as causas de aumento contidas na denúncia, eis que não há demonstração alguma nos autos quanto à alegada utilização de armas de fogo, de que se tratasse de tráfico interestadual ou, ainda, do envolvimento de criança ou adolescente. Realmente, não ficou demonstrada a origem das drogas, ao passo que não se apreendeu nenhuma arma e tal circunstância tampouco foi relatada por qualquer das testemunhas. Do mesmo modo, não consta dos autos o envolvimento de criança ou adolescente nos fatos investigados. Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que Anderson possui uma condenação anterior transitada em julgado (PEC 0000888-83.2017.8.26.0515 - fls. 3127), sendo certo que ainda permanecia em cumprimento da pena por ocasião dos presentes fatos, cf. fls. 3403, de modo que deve ser considerado reincidente. No mais, não possui outros antecedentes criminais. Outrossim, reza o art. 42 da Lei nº 11.343/06 que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. No caso dos autos, ausente apreensão das substâncias, não há como se majorar a pena acima do mínimo pela natureza ou quantidade das substâncias. No mais, as demais circunstâncias são normais ao tipo. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa, fixados no mínimo legal, à míngua de maiores informações quanto à capacidade financeira do acusado.

Na segunda fase, como visto, o acusado é reincidente. Não há atenuantes. Assim, majoro a pena de 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição da pena, de sorte que torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Diante da reincidência do acusado e da quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo cabível, outrossim, a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos ou a concessão de sursis no caso, diante do total da reprimenda ora aplicada.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o acusado recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro processo.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto na Lei nº 12.736/12, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para análise quanto ao preenchimento do elemento subjetivo necessário para a concessão do benefício (bom comportamento carcerário), de modo que compete ao Juízo da Execução Criminal a apreciação da questão.

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, ANULO a ação penal, desde seu início, em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 imputado ao acusado MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA, já qualificado nos autos, pois já processado anteriormente pelos mesmos fatos; no mérito, JULGO a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) condenar ANDERSON APARECIDO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, fixados no mínimo unitário legal; b) absolver NORIVALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, WESLEI AMARAL JACUBOVSKI, JOÃO DE DEUS, YAGO DIAS DE OLIVEIRA, MATEUS ARAÚJO DOS SANTOS, LEONARDO DE SOUZA AZOLINI, CÍCERA GERALDA DOS SANTOS e LEANDRO BATISTA SIQUEIRA, já qualificados nos autos, quanto aos crimes previstos no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; c) absolver MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA e ANDERSON APARECIDO DA SILVA, já qualificados nos autos, quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tendo sido apreendidas drogas nos autos, deixo de determinar sua incineração. Declaro perdidos os objetos e valores apreendidos relacionados ao acusado Anderson, pois o conjunto probatório revela serem utilizados para a prática do crime. Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade responsável para que possam ser tomadas as providências cabíveis para destinação/destruição do bem. Quanto a objetos e valores pertencentes aos demais acusados, deverão ser oportunamente restituídos aos proprietários.

Deferida na oportunidade a gratuidade processual aos réus.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor dos patronos nomeados pelo convênio DPE/OAB.

P.I.C.

Primavera, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA